

1500339-94.2022.8.26.0459
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
Comarca: Pitangueiras
Foro: Foro de Pitangueiras
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 31/10/2022
... Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 07.02.2019)

Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas - Descabimento - Conjunto probatório apto à condenação do réu pelo delito de tráfico - Intuito mercantil comprovado nos autos - Dosimetria - Pena-base acrescida de 1/6, nos termos do art. 59, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pitangueiras
Foro de Pitangueiras
1ª Vara
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500339-94.2022.8.26.0459 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500339-94.2022.8.26.0459
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209344/2022 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 26506289 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 2209344 - DEL.POL.PITANGUEIRAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY FRANCISCO TEIXEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia (fls. 83-84) em face de Wesley Francisco Teixeira, com qualificação nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta na peça acusatória que, no dia 02.08.2022, por volta de 17h10, na Rua Paschoal de Felício, altura do número 144, Centro, nesta cidade e comarca de Pitangueiras, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, quarenta e um invólucros plásticos (tipo "zip lock") contendo porções de crack, com massa líquida de 4,9 gramas, assim como cinquenta e um eppendorfs contendo cocaína em pó, com

massa líquida de 30,1 gramas, tratando-se de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, no dia dos fatos, o acusado, visando a prática da traficância, em local já conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas, teria trazido consigo as drogas supracitadas, acondicionadas dentro de duas sacolas plásticas, as quais seriam destinadas a consumo de terceiros.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu teria avistado a aproximação de uma viatura da Polícia Militar e, por isso, arremessado as duas sacolas sobre o telhado do imóvel situado naquela rua, mais precisamente com o nº 144.

Não obstante a tentativa de fuga, o réu teria sido detido e confessado, informalmente, que estava ali vendendo drogas e que havia arremessado as duas sacolas plásticas.

Em busca no telhado do imóvel, os policiais teriam encontrado as sacolas contendo as drogas supramencionadas em seu interior, além de R\$ 114,00.

Segundo o Ministério Público, além da confissão perante o Delegado, as circunstâncias da prisão (em conhecido ponto de tráfico de drogas), a quantidade e variedade de entorpecentes, a forma como estavam embalados (em porções individuais, prontas para a venda), bem como a existência de dinheiro evidenciariam que as drogas seriam destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (decisão às fls. 56-59).

O acusado apresentou defesa prévia às fls. 93-103.

Decisão (fls. 114-119) que recebeu a denúncia em 21.09.2022, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, indeferiu o pedido de liberdade provisória, indeferiu a instauração de incidente de insanidade e designou audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e houve a realização de interrogatório do acusado.

Oferecidas alegações finais pela Acusação, que reiterou o pedido de procedência da ação, requereu o reconhecimento da confissão do acusado. Requereu a condenação do acusado, com exasperação em razão da quantidade e da natureza das drogas. Na segunda fase, não se opôs ao reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, requereu o afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e fixação de regime inicial fechado. Requereu o afastamento da pena corporal por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

Em alegações finais, a Defesa sustentou que o acusado não é conhecido dos meios policiais como traficante. Alegou que o acusado é usuário de drogas e se dedicou, no momento, à traficância, em função de seu vício. Sustentou que a intenção do réu era o uso de entorpecentes, pleiteando a desclassificação ao artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Requereu o reconhecimento da confissão. Sustentou, subsidiariamente, que o acusado preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Requereu a diminuição da pena no grau máximo, em função da primariedade do acusado, fixação da pena no mínimo legal. Requereu, subsidiariamente, fixação da pena em regime inicial aberto ou semiaberto, com substituição de pena privativa liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede a pretensão acusatória à condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, tal como constou à fl. 115, em que pese o pedido da Defesa, não há prova ou elemento nos autos de que o acusado não fosse, à data dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Os policiais, ouvidos em Juízo, informaram que o acusado aparentava estar em estado normal ao momento da ocorrência. O réu, igualmente, afirmou que, em que pese a condição de usuário, exercia outras atividades.

Não houve apresentação de qualquer prova ou indício de eventual inimputabilidade, nem com documentos referentes à saúde do réu, de modo não há, neste feito, dúvida

sobre a capacidade do acusado.

Além disso, a condição de usuário de entorpecente não é suficiente para, isoladamente, resultar em inimizabilidade, sendo indispensável a constatação de ausência de capacidade para compreensão ou autodeterminação, o que não ocorre na hipótese vertente.

A materialidade do delito em testilha encontra-se comprovada nos autos pelos documentos de fls. 1-24 (auto de prisão em flagrante); fls. 16 (auto de exibição e apreensão); fls. 17 (auto de constatação); fls. 75-77 (laudo pericial), além do depoimento das testemunhas, não restando qualquer dúvida quanto à existência dos eventos criminosos narrados na peça vestibular.

Laudo pericial à fl. 76 em que houve a constatação de substância cocaína (i) em material sólido petrificado referente a 41 invólucros plásticos correspondente à massa líquida de 4,9g e (ii) em material sólido particulado referente a 51 microtubos plásticos correspondente à massa líquida de 30,1g.

Auto de exibição e apreensão à fl. 16, com a apreensão de R\$114,00 em notas diversas.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestas em apontar a responsabilidade penal do acusado.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Anestor Gonçalves Lima Junior disse que estavam efetuando patrulhamento pelo bairro, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que viram o acusado, estava com uma sacola na mão, quando ele viu a presença da equipe tentou arremessar a sacola ao telhado de uma casa e tentou se evadir. Disse que a equipe fez a abordagem dele, perguntou o que ele tinha jogado, ele disse que não tinha jogado nada, voltaram ao local, encontraram a sacola. Depois ele disse que tinha arremessado duas sacolas, em revista pessoal encontraram R\$114,00 em notas e drogas na sacola. Disse que perguntaram a ele sobre as drogas e ele disse que era dele e ele estava vendendo. Disse que não conhecia o acusado por envolvimento com tráfico, mas o parceiro dele já conhecia. Disse que no momento em que ele foi abordado ele estava lúcido, não aparentava estar sob efeito de drogas.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Eliezer Fabiano Arcênio disse que estava ele e Anestor em patrulhamento, subiram a rua, avistaram Wesley próximo ao número 144 da Pascoal de Felício, estava com sacola na mão, quando avistou a viatura ele arremessou. Disse que questionado o que ele tinha jogado, ele confessou que estava traficando e que tinha jogado duas sacolinhas com droga. Disse que o local é conhecido ponto de drogas. Disse que anteriormente o réu tinha sido preso pela equipe do policial também no tráfico de drogas. Disse que nesse dia tinham visto o acusado na parte da manhã no local, sem motivação para abordagem. Em outros serviços anteriores à noite, ele também foi visto no local, sem motivos para abordagem. Disse que a mãe dele disse que ele é usuário de entorpecente, mas nunca o viu utilizando. Disse que sabe que ele foi preso uma vez por tráfico de drogas. Disse que no momento da prisão, aparentemente, o réu estava normal.

Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade.

Nessa condição devem ser aceitos como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado o ônus de contrastá-los, o que não fez. Anote-se, ademais, que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações comportam acolhimento, especialmente se não demonstrado interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa desconhecida, como no caso em exame.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por fim a incriminação de uma pessoa inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer indício de irregularidade na conduta dos policiais.

A testemunha Vânia Regina Jacob disse que é motorista de aplicativo. Disse que conhece o acusado, disse que já viu o acusado usando drogas ou sob efeito de drogas. Disse que tem conhecimento de que o réu já foi internado em clínica de

reabilitação. Disse que já viu o réu exercendo a profissão de servente de pedreiro. Em seu interrogatório, o acusado afirmou que as drogas estavam com o acusado, porém teve tratamento clínico, no momento estava desempregado por dois dias e recebia chamado para vender drogas. Disse que iria vender as drogas. Disse que no momento em que foi preso as drogas que ele pegou era para consumo dele, nesse dia já tinha vendido drogas. Disse que estava vendendo droga só esse dia. Disse que a droga era pagamento, o dinheiro também. Disse que as porções de entorpecentes custam 5 reais cada uma. Disse que estava desde as 7 da manhã no local. Disse que ficou internado, inclusive 3 vezes sem o seu consentimento. Disse que é dependente químico. Disse que usava, mas também trabalhava.

Há prova suficiente nos autos a demonstrar a autoria delitiva. Nota-se que os entorpecentes e a quantia em dinheiro foram apreendidos em sacola que estava na posse do acusado, que se encontrava em local conhecido pelos policiais como ponto de venda de entorpecentes.

Os policiais afirmaram que o próprio acusado confessou a prática da mercancia ilícita, o que foi confirmado pelo réu em sede judicial.

A variedade de entorpecentes encontrada em local conhecido por ponto de venda de entorpecentes, em conjunto com dinheiro trocado e as circunstâncias da prisão em flagrante, denotam incompatibilidade com uso pessoal e indicam habitualidade na referida mercancia.

Assim, não é verossímil a alegação de que os bens seriam destinados ao consumo do acusado, razão pela qual não é cabível a desclassificação do delito descrito na exordial.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe o acusado qualquer prova ou argumento que pudesse afastar a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixação da pena

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado era tecnicamente primário na data dos fatos, sem condenações anteriores aos fatos que contassem com trânsito em julgado.

Contudo, as circunstâncias do delito devem ser sopesadas, tendo em vista a natureza da substância apreendida (crack e cocaína), bem como sua variedade. Assim, fixo a pena-base acrescida em 1/6, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa de dosimetria, ausentes agravantes. Entretanto, aplica-se a atenuante da confissão, o que retorna a pena intermediária ao patamar mínimo, a saber, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Houve a apreensão de quantidade de entorpecentes que não é diminuta, de alto potencial lesivo (crack e cocaína), em conjunto com numerário sem justificativa quanto à sua procedência.

Em síntese, não só o acusado se encontrava em ponto de venda de entorpecentes com as drogas que foram apreendidas, mas também foi descrito como sendo visto pelo policial em outras oportunidades no mesmo local e mantinha em sua posse quantia em dinheiro, tendo, ademais, confessado a traficância.

O policial Eliezer Fabiano Arcênio informou que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática do mesmo delito e houve a juntada de certidão de fl. 152-153 e fls. 158-159 que demonstra que o acusado foi condenado em primeiro e em segundo grau em outro processo, em função da suposta prática do mesmo delito, o que confirma a afirmação apresentada pelo policial militar em Juízo.

Em que pese a primariedade técnica do acusado, uma vez que não há trânsito em julgado de título penal condenatório, tendo em vista a reiteração de conduta semelhante, não é crível, tal como alegado pelo Ministério Público, que, se trate

de eventual neófito na prática da mercancia ilícita, em especial, diante do considerável valor correspondente às drogas que foram apreendidas com o réu na atual oportunidade, conforme o próprio acusado informou em interrogatório sob o crivo do contraditório.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade e variedade de entorpecentes, o dinheiro trocado sem comprovação de origem lícita, além dos depoimentos prestados pelos policiais, são fatores que demonstram, em conjunto, a dedicação do agente às atividades criminosas, o que afasta o pressuposto previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não lhe sendo cabível a aplicação do redutor, apesar da primariedade técnica. Nesse sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Cuidando-se de maior quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, faz-se incabível a aplicação do redutor legal específico disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006." (TJSP; Apelação 0003811-35.2016.8.26.0348; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017).

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstâncias judiciais do caso concreto que impõem a exasperação da pena-base. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessária a fixação do regime inicial fechado. Recurso da ré não provido e recurso Ministerial provido." (TJSP; Apelação Criminal 1502085-46.2020.8.26.0530; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Destarte, consolida-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em função da ausência de informações sobre a situação econômico-financeira do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, porque, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis e a pena foi fixada no patamar de 5 (cinco) anos, sem o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Além disso, em função da gravidade em concreto do delito e da quantidade e variedade de entorpecentes, não se demonstra recomendável regime inicial menos gravoso para a repressão da conduta delitiva. Sobre este aspecto:

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso da defesa absolvição por insuficiência probatória Improcedência Os firmes e coesos depoimentos dos policiais civis reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a variedade, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos são fatores que evidenciam a mercancia ilícita Tráfico bem caracterizado Condenação mantida. Dosimetria Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade Acusados que se dedicam a atividades criminosas, não se tratando de "marinheiros de primeira viagem" Fixação de regime prisional mais brando Não cabimento Regime fechado condizente com a gravidade concreta do delito, especialmente analisando-se a natureza e a quantidade dos entorpecentes Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos Inviabilidade Benesse vedada, seja em razão do "quantum" da reprimenda, seja em face da quantidade e natureza das drogas Aplicação da detração penal Não incidência Detração que deverá ser mais bem analisada na fase de execução Recursos defensivos improvidos. (TJSP, 8 Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 0001812-68.2017.8.26.0459, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 07.02.2019)

Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas - Descabimento - Conjunto probatório apto à condenação do réu pelo delito de tráfico - Intuito mercantil comprovado nos autos - Dosimetria - Pena-base acrescida de 1/6, nos termos do art. 59, do Código Penal - Réu portador de maus antecedentes - Atenuante da confissão não configurada - Réu que admitiu apenas a posse da droga, não a destinação comercial - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, corretamente afastado - Requisitos não preenchidos - Pena inalterada - Regime fechado escorreito e mantido - Pleito para que seja garantido o direito de recorrer em liberdade - Réu que permaneceu preso durante toda a instrução - Inalteradas as circunstâncias que motivaram a segregação cautelar - Restituição de valores em dinheiro apreendidos - Não acolhimento - Origem lícita não comprovada - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500195-32.2020.8.26.0608; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Tendo em vista o montante da pena, deixo de substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspender sua execução (art. 77 do CP). No caso dos autos não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em especial diante da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. É, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Considerando o lapso ainda restante para que se possa vislumbrar eventual progressão, considerando a pena fixada e a data do encarceramento provisório, deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional do sentenciado. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012.

Em razão da natureza do crime, fica prejudicado o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Wesley Francisco Teixeira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Em análise ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não houve a apresentação de elementos suficientes a afastar a custódia cautelar já determinada nestes autos. O sentenciado não poderá apelar em liberdade, dada à gravidade concreta do crime praticado, causador de intranquilidade social. Ademais, o réu aguardou o julgamento preso, nada justificando que agora, quando certa a sua responsabilidade criminal, seja solto, inclusive porque poderia frustrar o cumprimento da pena ora imposta. Assim, porquanto presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória ao acusado, de modo que mantenho a prisão preventiva. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Determino o perdimento do numerário apreendido (fls. 16), em favor da União, nos termos da lei, por se tratar de proveito do delito. Providencie-se o necessário após o trânsito em julgado, devidamente certificado.

Com o trânsito em julgado: (1) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (2) expeça-se guia de recolhimento definitiva; (3) expeça-se certidão referente à multa e abra-se vista ao Ministério Público para adoção das eventuais providências pertinentes; (4) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (5) oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de

São Paulo para cadastro de dados criminais; (6) oficie-se à Autoridade Policial para que providencie a destruição de eventual da droga apreendida para contraprova, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida ao acusado (pedido à fl. 103). Certifique-se a existência de Habeas Corpus ou de qualquer outra ação ou recurso pendente de julgamento, relativo ao presente processo, e, em caso positivo, oficie-se ao Tribunal ou Juízo competente, informando-se o teor desta sentença.

P.I.C

Pitangueiras, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA